

1502113-43.2019.8.26.0079
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/07/2022
... já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502113-43.2019.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502113-43.2019.8.26.0079
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2246676/2019 - 1º Distrito Policial de Botucatu, 1257/2019 - DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCIO GILBERTO DO NASCIMENTO MAGRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos

MARCIO GILBERTO DO NASCIMENTO MAGRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, em concurso material, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 00h21min., na Rua Domingos Garcia, nº 174, Vila Cidade Jardim, nesta cidade e comarca, foi surpreendido mantendo em depósito (01) um silenciador sem marca aparente (acessório de uso restrito), bem como (103) munições calibre 22, sendo 101 íntegros e 2 picotados; (12) munições calibre 32, sendo 11 íntegras e 1 picotada; (01) carabina calibre 22 da marca CBC e (01) revólver calibre 22 da marca Rossi, armas e munições de uso permitido, fazendo-o em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

Policiais militares foram acionados, inicialmente, para o atendimento de desentendimento entre o denunciado e sua mulher. Ocorre que, ao chegarem no local dos fatos, a esposa do denunciado indicou a existência de armas e munições ilegais, autorizando a entrada dos policiais no interior da residência.

A denúncia foi recebida (fls. 71/72), o réu citado (fls. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 90). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 93). Em seguida, em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Nos debates escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 161/166).

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, pela excludente do estado de necessidade.

Subsidiariamente pleiteou a desclassificação do artigo 16 para o artigo 12 da Lei 10826/03. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e aplicação do regime aberto (fls. 151/157).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

É caso de procedência da ação penal.

A materialidade criminoso ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo pericial (fls. 60/64) e pela prova oral produzida.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha Cynthia Suzana Cintas Mendoza disse que estavam com uma pizzaria na sua casa. Seu marido se alterou um pouco porque bebeu. Na época, o seu genro trabalhava junto com a declarante na pizzaria, era um delivery. Gustavo chegou, foi entrando na casa e Marcio não gostou muito, um retrucou com o outro e iniciou uma briga. Entrou no meio. Nunca tinha visto eles se alterarem daquele jeito e se assustou. O menino era bem atrevido e não respeitava regras. Nesse tempo, sua filha tinha acabado de ganhar o filho, estava com dois meses e foi uma situação que não soube lidar no momento. Eles se levantaram para brigar e a declarante foi no meio, cada um foi para um canto. Estava indo para o seu quarto com as crianças e viu o Marcio entrando. Ele tem um cofre onde guarda dinheiro e documentos, e ele foi mexer e se assustou, achando que ele iria pegar uma arma. Toda vez que ele fica bravo vai lá, mexe, pega dinheiro e sai, pois, ele não deixa o dinheiro em qualquer lugar. Assustou-se bastante, pois tinha criança no local. Eles se agrediram verbalmente. Viu o acusado pegando alguma coisa. Achou que fosse uma arma, só falou, pois, assiste muita coisa de investigação. Foi ela quem chamou a polícia. Sabia que ele tinha arma, pois a pizzaria era na edícula de casa e o portão ficava aberto até 1:30h e perto há muito tráfico de drogas. Mas ele nunca tirou de dentro do cofre. A polícia encontrou a arma. Não sabe qual tipo de arma. Estava com as crianças no quarto, quem acompanhou as buscas foi a sua filha. Viu que encontraram munições, mas não sabe calibre. Encontraram as munições no quarto, mas ele nunca usou para ameaçar ninguém. Encontraram a carabina sobre o guarda roupa.

Caroline Roberta de Camargo, policial militar, afirmou que foram acionados por conta de uma desinteligência entre casal e no local a esposa indicou que ele tinha uma arma guardada. Não se recorda qual a arma localizada. Ele tinha um silenciador também. Lembra-se de ter apreendido uma arma, silenciador e munições. Não se recordou se eram uma ou duas armas. Não se recordou onde estavam e a justificativa apresentada. As armas e munições foram indicadas pela esposa. Não se recordou se as armas estavam municiadas.

Renato Cristiano Marçal, policial militar, afirmou que foi uma ocorrência de desinteligência familiar entre marido e mulher. Deslocaram-se até o local e com as partes mais calmas, ela relatou que o réu possuía armamento na residência. Pediram apoio e com a autorização dela, que acompanhou, fizeram a revista na casa. No local foram localizadas munições, revólver, uma espingarda e silenciador. Não se recordou se o réu deu alguma versão. Ele não tinha autorização para nenhum dos armamentos. O réu confessou a prática delitiva em sede policial. Confirmou que os militares entraram em sua casa, com a autorização de Cynthia, e encontraram no quarto a

espingarda da marca CBC, calibre 22, mais a munição do mesmo calibre e um silenciador, tudo guardado dentro de uma capa de tecido. Relatou que os militares também encontraram o revólver da marca rossi que estava escondido atrás de um quadro na sala da casa (fls. 12/13). Em juízo, disse que teve uma discussão com o genro da sua esposa. Não se agrediram. Sua esposa chamou a polícia e relatou que tinha as armas em casa e de livre e espontânea vontade entregou as armas e indicou onde elas estavam. O interrogando foi quem abriu o cofre e entregou as munições. Havia uma pizzaria nos fundos de casa e o portão ficava aberto até altas horas da noite. A sua vila não é segura. Acabou adquirindo as armas para a sua segurança e de sua família.

Consoante se extrai da prova oral acima, inconteste que o acusado possuía e mantinha sob guarda, no interior de sua residência, arma e munições de uso permitido e silenciador (acessório de uso restrito), mormente pela confissão do réu, a qual restou corroborada pelos depoimentos da esposa do réu e dos policiais. Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Os laudos periciais concluíram que a armas e as munições estavam em boas condições de conservação e uso.

Os artefatos foram apreendidos porque o acusado não possuía autorização para mantê-los em sua residência.

Exsurge, portanto, que o réu possuía, de forma irregular, arma de fogo e munições em condição de uso e funcionamento, sendo hábil a ofender a integridade física de outrem. Agiu, pois, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ao mantê-las no interior de sua residência.

Mais a mais, não se discute, aqui, a finalidade que o acusado daria ao instrumento, já que se trata de crime de perigo abstrato.

Com efeito, a simples posse ou guarda de armas e munições por indivíduo que não possua autorização para tanto, gera intranquilidade social, por facilitar a prática de outros crimes graves.

Neste sentido, coleciono o entendimento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART.16 DA LEI 10.826/2003. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPLICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir se a ordem de ofício. - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo, portanto, irrelevante que a munição esteja desacompanhada da respectiva arma. Habeas corpus

não conhecido." (STJ HC 244.700/MG 6ª T. Rel. Min. Marilza Maynard j. 20.03.2014 DJU 10.04.2014).

Com todo respeito ao nobre e combativo Defensor, não há que se falar em reconhecimento de excludente de ilicitude, pois a situação apurada nos autos não revelou, em qualquer momento estado de necessidade, modalidade prevista no artigo 23 do Código Penal.

Não se pode alegar que há estado de necessidade, que exige perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não restou demonstrado. "Se o conflito estabelecido entre os bens puder ser solucionado de modo diverso, como por um pedido de socorro a terceira pessoa ou pela fuga do local do perigo, o fato não se considerará justificado, pois a conduta lesiva deve ser o único meio de salvar o bem do perigo" (ESTEFAM, André. Direito penal: parte geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018).

Outrossim, ainda que se adotasse como verdadeira a premissa defensiva (segurança da família em virtude de ser um imóvel comercial – pizzaria), certo é que existem vias legais para a defesa da propriedade, preferindo o réu, contudo, o caminho do crime. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO Pretendida absolvição sob a alegação de estado de necessidade Impossibilidade Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução Confissão do acusado, aliada aos demais elementos de convicção que dão a certeza do cometimento do delito pelo acusado Ademais, excludente que exige, para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, não demonstrado no caso concreto Condenação mantida (...) ".(TJSP; Apelação Criminal 0003459-72.2015.8.26.0070; Relator(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Batatais - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018

Também não se acolhe a tese de erro de tipo quanto ao silenciador (acessório de uso restrito), pleiteando a defesa a desclassificação do delito do artigo 16 para o artigo 12 da Lei 10826/03, visto que o desconhecimento da lei é inescusável. Assim, a conduta praticada pelo réu se amolda perfeitamente àquela descrita na denúncia, porquanto flagrado possuindo silenciador, cabendo ressaltar que em nenhum momento o réu afirmou que não tinha ciência de que a posse de tal acessório de uso restrito constituía crime.

Por fim, estando o acusado, no mesmo contexto fático, a possuir arma de fogo e munições de uso permitido (sem registro) e acessório de uso restrito (silenciador), dois delitos foram praticados mediante ação única e considerando que as objetividades jurídicas dos crimes são distintas, aplica-se o concurso formal de crimes, conforme precedentes abaixo.

APELAÇÃO. Posse de munição de uso restrito e posse de munição de uso permitido. Recurso defensivo. Redução de ofício da pena-base. Ações penais em andamento não têm o condão de elevar a pena-base. Inteligência da Súmula 444 do STJ. Pleito de reconhecimento do concurso formal de delitos. Cabimento. Prática, no mesmo contexto fático, dos crimes previstos no artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03. Fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso provido (TJSP, Apelação nº 0005648-24.2014.8.26.0663 Rel. Ministro LEME GARCIA - 16ª Câmara Criminal, julgado em 02.08.2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. I - O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas.II - In casu, conforme consignado no decisum reprochado, muito embora haja a consumação

de crimes de posse irregular de arma de fogo e porte de munição de uso permitido e de uso restrito, referidas condutas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime meio e crime-fim. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1863921/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe04/05/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO,IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de aplicação, no caso concreto, da regra do concurso formal entre os delitos dos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, de munição, de acessório ou de explosivo, com o mesmo agente, não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 4. Tem- se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático,mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 5. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático,configuram concurso formal de delitos. [...] O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1825695/MG, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado os delitos previstos no artigo 12 e no artigo 16, ambos da Lei 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da aplicação da pena do crime mais grave (artigo 16), observo que o réu não possui antecedentes (fls. 27/28). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão.

Na segunda fase, deixo de atenuar a pena em razão da confissão, porque já no piso. Na terceira fase, reconheço o concurso formal entre os crimes dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 (art. 70 do CP) e aumento a pena em 1/6, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Considerando o disposto no art. 33, § 3º, do CP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCIO GILBERTO DO NASCIMENTO MAGRO à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela

prática do crime previsto no artigo 12 caput e artigo 16 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 70 do Código Penal.

O réu preenche os requisitos do artigo 44, incisos de I a III, do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, além de prestação pecuniária, consistente na entrega de uma cesta básica no valor de 01 salário mínimo vigente à data do pagamento para entidade pública ou privada com destinação social, deste Município, também a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Nos termos do artigo 25, da Lei Federal nº 10826/03, bem como consoante a Resolução nº 134 do Conselho Nacional de Justiça, encaminhe-se as armas de fogo, munições e acessório apreendidos ao Comando do Exército para a sua destruição ou doação.

Faculto ao réu o recurso em liberdade, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Botucatu, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA